

1501485-34.2019.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANILO BRAIT

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... de Freitas Evangelista pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, absolvendo-o em relação ao delito de associação para o tráfico. Com relação à corré Tamires Mayara Rodrigues da Silva, impõe a absolvição em relação a ambos os delitos, conforme doravante será exposto.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou demonstrada pelo auto de prisão em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

1501485-34.2019.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501485-34.2019.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TAMIREs MAYARA RODRIGUES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT.

Vistos.

DAVI VINICIUS DE FREITAS EVANGELISTA e TAMIREs MAYARA RODRIGUES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 33, "caput", e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, em data e lugar incertos, porém, anteriormente ao dia 25 de setembro de 2019, na Rua Isamar, nº 612, Fundos, no bairro Jardim Rosele, nesta cidade e comarca de Araçatuba-SP, os réus associaram-se com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Consta ainda que, no dia 25 de setembro de 2019, na Rua Isamar, nº 612, Fundos, no bairro Jardim Rosele, nesta cidade e comarca, os réus, agindo com unidade de propósitos e desígnios entre si, tinham em depósito e guardavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 45,48 gramas, distribuídas em 54 (cinquenta e quatro) microtubos plásticos contendo a substância benzoilmetilecgonina (cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os acusados foram presos em flagrante em 25/09/2019 (fls. 06/07). Pela r. decisão de fls. 64/67, a prisão em flagrante do acusado Davi Vinicius de Freitas Evangelista foi convertida em prisão preventiva, sendo concedida a liberdade provisória em favor da ré Tamires Mayara Rodrigues da Silva, com aplicação de medidas cautelares. Mandado de prisão e alvará de soltura cumpridos em 26/09/2019 (fls. 72/75).

Devidamente notificados, os réus apresentaram defesa prévia às fls. 121/125 e 133/134. A denúncia foi recebida em 04 de março de 2020, ocasião em que foi deferida a gratuidade de justiça em favor dos réus (fls. 166/168). Sobreveio r. decisão judicial de fl. 184, deferindo a liberdade provisória em favor do acusado Davi Vinicius de Freitas Evangelista, com aplicação de medidas cautelares. Alvará de soltura cumprido em 20/03/2020 (fls. 191/193). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas em comum, sendo, ao final, interrogados os acusados (fls. 247/249 e 292/299).

Em alegações finais (fls. 303/308), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela absolvição dos acusados, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais (fls. 311/313), a Defesa da acusada Tamires Mayara Rodrigues da Silva pugnou, em síntese, pela absolvição da ré, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais (fls. 319/324), a Defesa do acusado Davi Vinicius de Freitas Evangelista suscitou, preliminarmente, a ilegalidade do ingresso dos policiais militares na residência do réu. No mérito, em síntese, requereu a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como a restituição da quantia e do aparelho celular apreendidos nos autos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

De início, não há que se falar em violação de domicílio praticada pelos policiais militares no caso vertente.

Segundo consta dos autos, os policiais realizavam patrulhamento quando foram abordados por um transeunte, que não quis se identificar. O denunciante informou que estaria ocorrendo o tráfico de drogas na residência situada na Rua Isamar, nº 612, fundos, sendo que ao chegarem no local, os agentes públicos surpreenderam os acusados saindo do imóvel, ocasião em que foram abordados. Os policiais militares e os próprios réus declararam em solo judicial que o portão da residência estava aberto, sendo possível visualizar no interior do imóvel a caixa de energia aberta, com uma sacola plástica à mostra, sendo que os agentes públicos foram até o local e localizaram 101 (cento e um) pinos de cocaína vazios e duas peneiras pequenas, com resquícios da droga.

Em razão disso, os policiais decidiram averiguar a residência dos acusados, tendo as testemunhas afirmado, tanto na seara inquisitiva (fls. 08/09) quanto em juízo,

que a ré Tamires Mayara Rodrigues da Silva autorizou o ingresso na residência e acompanhou as diligências no interior da casa, ocasião em que foram encontrados no quarto do casal, dentro da gaveta do criado mudo, um saquinho contendo 54 (cinquenta e quatro) pinos cheios de cocaína, idênticos àqueles que foram encontrados na caixa de energia.

Consta também, de acordo com os depoimentos prestados pelos agentes públicos em juízo, que o acusado Davi já era conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas – inclusive, foi preso anteriormente pela testemunha Wagner Antonio da Silva –, bem como o padrasto do réu, Sr. Paulo Roberto da Silva, morador da residência ao lado, estava presente e acompanhou as diligências que culminaram na apreensão dos entorpecentes.

Como é cediço, o E. Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015).

Neste contexto, “o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (STJ, REsp nº 1.558.004/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/08/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017).

Em análise ao caso dos autos, ressalto que o delito de tráfico de drogas possui como característica a permanência, de modo que é facultado ao agente policial o ingresso na residência, independentemente de ordem judicial ou acompanhamento do acusado, a fim de cessar a prática delituosa (artigo 303 do Código de Processo Penal). Com efeito, o próprio dispositivo constitucional que consagra a garantia da inviolabilidade de domicílio excepciona os casos de flagrante delito (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal). Assim, o agente que, em tese, tem em depósito e guarda substância entorpecente, para fins de entrega a consumo de terceiros, está em situação de flagrância, a ponto de, por exceção constitucional, autorizar que a autoridade policial ingresse na residência mesmo sem mandado ou autorização do morador.

Portanto, evidenciado o flagrante pelo crime de tráfico de drogas, o ingresso no imóvel se mostra lícito e permitido, conclusão que, não só a Constituição acata, como a lógica recomenda: houvesse garantia absoluta, que modernamente não se concebe, o domicílio, equivocadamente alçado à fortaleza impenetrável, serviria não como proteção à intimidade e vida privada, mas à prática de graves ilícitos.

Vale dizer, restaram demonstrados nos autos os indícios concretos e razoáveis da existência de crime permanente, aptos a afastar a necessidade de autorização para ingresso na residência. Nota-se que os policiais receberam relatos da prática do tráfico de drogas no imóvel, sendo que ao abordarem os réus saindo da residência, com o portão ainda aberto, visualizaram a sacola plástica existente na caixa de energia, ocasião em que adentraram no imóvel e encontraram dentro da sacola vários microtubos vazios de cocaína e peneiras com resquícios da droga. Ressalta-se que o acusado Davi, segundo o testemunho policial, já era conhecido por tráfico de drogas, sendo que a corré Tamires autorizou o ingresso na residência, não havendo, neste ponto, qualquer nulidade, como quer fazer crer a defesa, sobretudo porque a denúncia e circunstâncias fáticas foram confirmadas pelo encontro das drogas.

Portanto, a tese defensiva de ilegalidade no ingresso dos policiais militares na residência não comporta acolhimento.

No mérito, o pedido inicial é parcialmente procedente, impondo-se a condenação do réu Davi Vinícius de Freitas Evangelista pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, absolvendo-o em relação ao delito de associação para o tráfico. Com relação à corré Tamires Mayara Rodrigues da Silva, impõe a absolvição em relação a ambos os delitos, conforme doravante será exposto.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 06), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, laudo de constatação prévia de substância entorpecente de fl. 19, laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 90/93, laudo pericial de fls. 94/98, relatório policial de fls. 114/115, bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria com relação ao acusado Davi Vinícius de Freitas Evangelista também é certa.

A testemunha comum Wagner Antônio da Silva, policial militar ouvido em juízo (fl. 249), em consonância com seu depoimento colhido na fase inquisitiva (fl. 08), disse que estavam em patrulhamento quando recebeu uma denúncia anônima, pessoalmente, de um rapaz que não quis se identificar, o qual informou que na Rua Isamar, nº 612, fundos, estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes. Ao chegarem à residência, avistaram os moradores Davi e Tamires saindo do imóvel. Os acusados foram abordados na calçada. Relatou que foram encontrados R\$ 302,00 em notas diversas com o réu Davi. Com a corré Tamires nada de ilícito foi localizado. O depoente se aproximou do portão, que estava aberto, e visualizou a caixa de energia do imóvel aberta, sendo que no interior tinha uma sacola à mostra. Disse que pegou a sacola, onde havia 101 (cento e um) pinos de cocaína vazios e duas peneiras pequenas com resquícios da droga. Questionou os acusados se havia algo de ilícito no interior da residência, sendo que a acusada Tamires negou e autorizou o ingresso na residência, acompanhando o depoente na diligência. A casa tinha três cômodos e um quarto apenas. No quarto, dentro da gaveta do criado mudo, o depoente encontrou um saquinho contendo 54 (cinquenta e quatro) pinos cheios de cocaína, idênticos àqueles que foram encontrados na caixa de energia. Diante da localização da droga, o acusado Davi confessou que o entorpecente lhe pertencia e que estava realizando o tráfico de drogas. Os réus foram conduzidos o plantão policial, sendo que na Delegacia o acusado Davi negou a propriedade dos entorpecentes encontrados. A acusada Tamires também negou a propriedade das drogas. Conhecia apenas o acusado Davi, o qual já tinha sido preso pelo depoente, também por tráfico de drogas. Disse que não foi solicitada a perícia no local dos fatos. Não tinham mandado de busca para ingressarem na residência, contudo, a ré Tamires autorizou a entrada e acompanhou a diligência, sendo que tal autorização foi registrada no boletim de ocorrência. Disse que o padrasto do réu Davi, Sr. Paulo Roberto da Silva, que morava na casa ao lado, numeral 612, foi convocado como testemunha para acompanhá-los nas diligências. Como a denúncia foi anônima e pessoal, bem como o indivíduo não quis se identificar, não fizeram o relatório de qualificação do denunciante. Não sabe descrever as características físicas do denunciante. Disse que aquela foi a primeira denúncia de tráfico de drogas no local recebida pelo depoente, porém, o acusado Davi era conhecido nos meios policiais e já foi preso anteriormente pelo depoente. A denúncia dizia que o casal estava no local traficando drogas, mas não sabe dizer que havia a prática reiterada do crime no local. Esclareceu que a residência tinha um portão de estatura média e fechada, porém, existe uma fresta entre a coluna e o portão, onde observaram o casal saindo da residência. A caixa de energia fica do lado de dentro do imóvel, porém, é visível pelo lado de fora do portão, sendo que o depoente avistou a sacola e entrou no imóvel para pegá-la. A acusada Tamires disse que não sabia da existência dos pinos no local, sendo que o corréu Davi assumiu a propriedade da droga.

A testemunha comum Anderson Luis Barbosa, policial militar ouvido em juízo (fl. 298), em consonância com seu depoimento colhido na fase inquisitiva (fl. 09), disse que receberam uma denúncia anônima sobre a prática do tráfico de drogas na Rua Isamar. Foram até o local e ao se aproximarem, o casal saiu da residência. O casal foi abordado. Em busca pessoal, encontraram uma quantia de dinheiro com o acusado Davi. Indagado se tinha algum entorpecente ou algo ilícito no interior da residência, o réu Davi disse que não. Relatou que na caixa de energia que fica entre o muro e o portão, encontraram um saco contendo vários pinos de cocaína e duas peneiras com resquícios da droga. O acusado Davi começou a ficar nervoso, alterado e gritava no meio da rua, sendo que apareceram populares no local. Por medidas de segurança, colocaram o réu no chão. Relatou que conversaram com a esposa de Davi, que franqueou a entrada na residência e disse que não havia nada no local. Contudo, durante as buscas, encontraram alguns pinos contendo cocaína no interior da residência, idênticos àqueles que estavam no portão. Disse que encontraram, aproximadamente, a quantia de R\$ 300,00 em notas diversas, com o acusado Davi. Na caixa de energia tinha um saquinho do tipo "zip-lock", contendo vários pinos, mas não recorda a quantidade exata. Os demais pinos foram encontrados numa cômoda da cama, aproximadamente, 50 (cinquenta) microtubos contendo cocaína. Nenhum dos acusados assumiu a propriedade da droga. Inicialmente, salvo engano, o acusado Davi assumiu a propriedade da droga, mas depois ele negou no plantão policial. Não recorda os valores das notas encontradas com Davi. Com a corré Tamires não foi encontrado nada de ilícito. Afirmou que Tamires autorizou a entrada dos policiais na residência. Na denúncia, não foi citado o nome da corré Tamires. Não tinham mandado de busca para ingressarem na residência. A denúncia foi anônima, mas não recorda as características físicas do denunciante. Não recorda onde foram abordados pelo denunciante. Não havia investigações preliminares e fundadas razões da prática do crime na residência. Salvo engano, a autorização para o ingresso na residência consta no boletim de ocorrência. O depoente não colheu a autorização da corré Tamires. Não recorda se há uma gravação de áudio ou vídeo com a autorização da acusada. Não recorda a cor dos pinos de cocaína. Salvo engano, tinha um morador do local, que era parente dos acusados, que acompanhou os policiais nas diligências e foi qualificado, mas não conduzido ao plantão policial. Não recorda como a droga foi acondicionada e levada até a Delegacia de Polícia. Salvo engano, foi o policial Wagner que encontrou a droga na residência, porém, o depoente não presenciou a apreensão. Não efetuou a abordagem de nenhum viciado em drogas que tenha adquirido entorpecente do acusado Davi na residência. Na ocasião, foram informados todos os direitos aos acusados. Os réus foram abordados saindo da residência, quando abriram o portão. Os pinos vazios estavam na caixa de energia. Disse que era possível visualizar a caixa de energia no portão, ocasião em que avistaram a sacola.

Em seu interrogatório em juízo (fls. 294/295), o réu Davi Vinicius de Freitas Evangelista disse que estava saindo com sua esposa e corré Tamires para comprar fraldas, sendo que abrirem o portão, encontraram os policiais que disseram se tratar de uma denúncia de tráfico. Relatou que um policial ficou com o interrogando e outros ingressaram na residência. O policial desferiu um soco no seu peito. Os policiais demoraram um pouco na residência e retornaram, sendo que foram até a viatura e um deles pegou uma sacola e colocou dentro da farda. Os policiais entraram novamente na residência e voltaram com a sacola dizendo que era do interrogando. Negou a propriedade da sacola, dos pinos vazios, peneiras e da droga apreendida. Não viu os pinos de cocaína. A sacola estava na parte de trás da viatura. Não viu o que tinha dentro da sacola. A droga foi apresentada ao interrogando somente na Delegacia. Os policiais não deram voz de prisão para a corré Tamires, tendo falado somente que iriam levar a corré junto com o interrogando para a Delegacia. Disse que reside no imóvel numeral 612. Afirmou que na data dos fatos o portão tinha uma chapa de metal que impedia a visão para o lado de dentro do imóvel. Quem está do lado de fora não consegue visualizar a caixa de energia no interior do imóvel. No momento da abordagem, o portão estava fechado. Os policiais não exibiram nenhum mandado de busca e apreensão. Afirmou que ninguém

autorizou a entrada dos policiais no imóvel. Disse que foi abordado quando estava saindo da residência. Estavam abrindo o portão para sair quando foram abordados.

Em seu interrogatório em juízo (fls. 296/297), a ré Tamires Mayara Rodrigues da Silva disse que estava saindo de casa com seu esposo e acusado Davi, para irem ao shopping, quando foram surpreendidos pelos policiais. Os policiais colocaram as armas na cara da interroganda e disseram que estavam ali devido a uma denúncia de tráfico de drogas. Afirmou que alguns policiais entraram na residência e outro ficou com o corréu Davi. A interroganda foi até a casa da frente, chamar a sua sogra. Os policiais chamaram a interroganda no quarto, que estava todo revirado, e lhe mostraram uma sacola, perguntando se ela sabia que ali havia droga, sendo que respondeu não. Os policiais disseram que encontraram a droga no quarto, mas ela disse que não tinha conhecimento do entorpecente no local. Os policiais mostraram para a interroganda um saco que continha pinos vazios e peneiras, dizendo que tinham encontrado na caixa de energia, mas ela não viu os objetos no local. Negou a propriedade da droga. Não sabe afirmar se a droga pertencia ao acusado Davi, pois a interroganda saía cedo para trabalhar e quando retornava o corréu já estava em casa, pois Davi trabalhava como servente de pedreiro com seu padasto, que residia na frente da casa. Não tem conhecimento se Davi é usuário de drogas. Teve um relacionamento amoroso com Davi por três anos e pouco. Soube apenas que Davi já foi preso. Afirmou que na época dos fatos o portão tinha uma chapa de metal que impedia a visão para o lado de dentro do imóvel. Quem está do lado de fora não consegue visualizar a caixa de energia no interior do imóvel. O portão estava encostado quando foram abordados. Na época dos fatos, trabalhava com carteira registrada e chegou do serviço por volta das 18h30min. Disse que ficou, aproximadamente, meia hora em casa e saíram para ir ao shopping, quando foram abordados. Relatou que um policial deu voz de prisão para a interroganda. Não autorizou a entrada dos policiais na residência. Nunca foi presa e nem processada criminalmente.

Eis a prova oral colhida.

Quanto ao delito de tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06) praticado pelo réu Davi Vinícius de Freitas Evangelista.

Encerrada a instrução processual, restou demonstrado que os entorpecentes e apetrechos apreendidos pertenciam ao acusado e destinavam-se à comercialização ilícita, diante do que foi declarado pelas testemunhas comuns em juízo, bem como pelas circunstâncias fáticas em que a droga foi encontrada.

Os policiais militares Wagner Antônio da Silva e Anderson Luis Barbosa confirmaram os fatos narrados na denúncia. Confirmaram em juízo que durante patrulhamento foram abordados por um indivíduo que não quis se identificar, o qual informou que na residência dos acusados estaria ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes. Ao chegarem no local, os agentes públicos surpreenderam os réus saindo do imóvel. Como o portão da residência estava aberto, a testemunha Wagner Antônio da Silva visualizou no interior do imóvel a caixa de energia aberta, com uma sacola plástica à mostra, ocasião em que foi até o local e localizou no interior da sacola 101 (cento e um) pinos de cocaína vazios e duas peneiras pequenas, com resquícios da droga.

Ato contínuo, a corré Tamires autorizou o ingresso dos policiais na residência e acompanhou as diligências, sendo encontrados no quarto do casal, dentro da gaveta do criado mudo, um saquinho contendo 54 (cinquenta e quatro) pinos cheios de cocaína, idênticos àqueles que foram encontrados na caixa de energia.

Segundo as testemunhas, naquela ocasião, foi encontrada certa quantia em notas diversas (R\$ 302,00 - fl. 16) com o acusado Davi, o qual assumiu a propriedade da droga e dos apetrechos.

Ainda de acordo com a testemunha Wagner Antônio da Silva, o denunciante informou que o casal estava praticando o delito na residência, sendo que o acusado Davi já era conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas, inclusive, já foi preso em ocasião anterior pelo policial militar.

Não há motivos para desmerecer as palavras dos policiais militares, uma vez que confirmadas pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e laudos periciais de fls. 19, 90/93 e 94/98.

Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si, estando em conformidade com os depoimentos colhidos na fase inquisitiva (fls. 08/09), o que lhes confere maior densidade probatória, não havendo nenhuma contradição que se presta a abalar, minimamente, a credibilidade das testemunhas.

Neste passo, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, visto que, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestarem testemunho sob o compromisso da lei.

No caso vertente, não há prova segura nos autos a sugerir que os policiais teriam mentido em juízo e “forjado” o flagrante da droga e apetrechos para tentarem prejudicar o acusado. Não há motivos para acreditar que abordaram o réu com a única finalidade de incriminá-lo e prendê-lo em flagrante, como alegou em seu interrogatório na fase judicial.

Ressalta-se que o acusado já foi preso em flagrante em outras ocasiões por tráfico de drogas – corroborando a versão narrada pela testemunha –, sendo-lhe aplicada medida de segurança (fls. 58/59). Embora tecnicamente primário, tal situação também demonstra que o acusado está envolvido no comércio ilícito de entorpecentes.

Como é cediço, o testemunho policial é de grande valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito.

Com efeito, “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

Caracteriza-se, portanto, a prova produzida, como mais um elemento no conhecimento dos fatos pelo julgador, que deve apreciá-la em conjunto com as demais provas existentes nos autos.

Quanto ao acusado, em que pese ter negado a prática do delito tanto na seara policial (fl. 11) quanto em juízo – afirmando que o flagrante da droga e apetrechos foi “forjado” pelos policiais militares, uma vez que não tinha em depósito e nem guardava os entorpecentes na sua residência –, observa-se que sua versão exculpatória não merece credibilidade, conforme anteriormente exposto, sendo infirmada pela prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A alegação defensiva de que era impossível os policiais militares visualizarem a caixa de energia no interior do imóvel, uma vez que o portão da residência era fechado (fl. 321), não merece prosperar, tendo em vista que tanto as testemunhas como os próprios acusados afirmaram em solo judicial que foram abordados quando o portão estava aberto.

Em pese a versão dos fatos narrada pelo réu tenha sido parcialmente corroborada pela corré Tamires, tenho que seu o depoimento deve ser visto com extrema cautela, pois se trata da companheira do acusado, possuindo com ele íntima relação de afinidade, bem como está sendo processada pela prática dos mesmos delitos imputados ao réu.

Ademais, a corré declarou em solo judicial que não pode afirmar se a droga era, ou não, do acusado, uma vez que saía para trabalhar cedo e quando retornava, Davi já estava em casa.

Imperioso ressaltar que as versões apresentadas pelo réu e sua companheira em juízo não foram corroboradas por nenhum outro elemento de prova colhido nos autos, tratando-se de versões frágeis e destituídas de qualquer suporte probatório que lhe deem sustentação.

O modo como a droga estava acondicionada e a quantidade apreendida configuram que se destinava ao tráfico. Isto porque foram apreendidos 54 (cinquenta e quatro) microtubos plásticos, do tipo eppendorf, na cor rosa claro, perfazendo o total de 45,48 gramas da substância entorpecente "cocaina" (fls. 19 e 90/93), prontas para a venda. De igual modo, no mesmo contexto fático, foram apreendidas 02 (duas) peneiras contendo resquícios da mesma substância entorpecente (fls. 94/98), além de diversos microtubos plásticos vazios da cor rosa (fl. 17), idênticos aos pinos encontrados no interior da residência, conforme relataram as testemunhas comuns.

Registre-se, ainda, que no mesmo contexto fático foram apreendidos R\$ 302,00 (trezentos e dois reais) em espécie, não tendo o acusado comprovado a origem lícita do dinheiro, o que corrobora com a versão policial de que estava traficando drogas no local dos fatos, uma vez que é comum que os agentes carreguem consigo os valores oriundos das vendas que realizam, demonstrando a relação do numerário com o comércio nefasto da droga.

Cabe ponderar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse ou guarda do tóxico pelo agente para entrega a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja ele flagrado em atos de mercancia, sendo irrelevante para a sua caracterização, no presente caso, o fato de os policiais não terem realizados diligências prévias, como a abordagem de usuários que teriam adquirido a droga do acusado.

A propósito, sobre o tema o E. TJ/SP já decidiu que: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP63/316, 70/371 e 97/512).

Portanto, as provas são robustas a sustentar um decreto condenatório, não merecendo acolhimento o parecer ministerial e a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal.



Com efeito, as condutas do réu, consistentes nas ações de “ter em depósito” e “guardar” o entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, encontram-se inseridas no rol descrito no “caput” do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Analisando os autos, é o caso de se aplicar a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 em favor do acusado, uma vez que é tecnicamente primário (fls. 52/55 e 58/60), não ostenta maus antecedentes e não restou comprovado pela acusação que se dedica às atividades criminosas e integra organização criminosa.

Portanto, em razão de todo o acima exposto, restou demonstrada e caracterizada a conduta do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao delito de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06) praticado pela corré Tamires Mayara Rodrigues da Silva.

Em consonância com o pedido formulado pelo órgão ministerial, pelo que se pode observar das provas produzidas nos autos, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas pela acusada.

Recai sobre a ré somente o fato de que os policiais militares receberam denúncia anônima informando a prática do delito por um “casal”, sendo que abordaram a acusada saindo do imóvel na companhia de Davi.

Ainda segundo as testemunhas, Davi assumiu a propriedade das drogas e apetrechos apreendidos, ao passo que a acusada negou saber da existência da droga na residência.

Registre-se também, que a testemunha Anderson Luis Barbosa afirmou em juízo que a denúncia não mencionava o nome de Tamires.

Observa-se que a acusada negou a prática do delito, tanto na seara policial (fl. 10) quanto em juízo, afirmando desconhecer os entorpecentes e apetrechos que foram apresentados pelos policiais militares, não sabendo informar se foram encontrados na residência e se pertenciam ao corréu Davi.

No mesmo sentido, seu deu o interrogatório do corréu Davi, negando o envolvimento de Tamires deste na prática delituosa.

Portanto, o conjunto probatório, no que tange à autoria, ressepte-se de robustez, mostrando-se insuficiente a comprovação da prática do delito por parte da acusada.

As provas coligidas não permitem a conclusão de que os entorpecentes e apetrechos apreendidos na residência também pertenciam a Tamires.

Neste contexto, apesar de haver indícios de que a acusada sabia da existência da droga no local, bem como de que ambos estariam exercendo a mercancia ilícita – uma vez que a denúncia mencionava a prática do tráfico de drogas pelo “casal”, a sacola plástica encontrada na caixa de energia estava à mostra, bem como os entorpecentes foram encontrados dentro do criado mudo localizado no quarto do casal –, tenho que tais circunstâncias, por si só, são insuficientes para apontá-la, no presente caso, como partícipe do delito, porquanto o conjunto probatório no que tange à autoria, ressepte-se de robustez, mostrando-se insuficiente à comprovação da prática do tráfico de drogas por parte da ré.

Assim, se é correto afirmar que há indícios da prática do crime de tráfico, o mesmo não se pode dizer sobre a existência de prova robusta e cabal para embasar um

decreto condenatório, exigência inafastável no presente caso, pois as provas produzidas nos autos não são contundentes nesse sentido, devendo prevalecer a cautela e a ponderação a fim de se evitar a condenação de alguém que possa ser inocente.

Desta forma, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, de bom alvitre a prolação do édito absolutório.

Quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

Através da prova testemunhal colhida em juízo, restou devidamente comprovado que somente o acusado Davi praticou a mercancia ilícita dos entorpecentes.

Entretanto, com relação ao crime de associação para o tráfico, leciona Guilherme de Souza Nucci: "Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico" (Leis Penais e Processuais Comentadas - Vol. 1; 11ª Edição, Editora Forense, 2018, pág. 417).

Da análise de toda a situação, bem como dos elementos fáticos extraídos dos autos, não se consegue verificar a existência de provas suficientes de que Davi e sua companheira Tamires se associaram com a finalidade de praticarem a mercancia ilícita.

Não se comprovou o caráter duradouro na união entre eles, sequer que mantinham a estabilidade, ou seja, a habitualidade para o cometimento dos crimes previstos na Lei de Drogas.

Neste sentido: "Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Dessa forma, é atípica a conduta se não houver ânimo associativo permanente (duradouro), mas apenas esporádico (eventual)" (STJ, HC nº 139.942-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/11/2012).

Assim, não é possível precisar que os acusados estavam associados para a traficância. Ausentes provas que evidenciem a associação para o tráfico, ônus que competia ao órgão ministerial e do qual não se desincumbiu a contento, deve prevalecer a não incidência do crime previsto no artigo 35 no presente caso, acolhendo-se o pleito ministerial e defensivo de absolvição quanto ao tipo penal.

Passo à fixação da pena do acusado Davi Vinícius de Freitas Evangelista quanto ao delito de tráfico de drogas.

No tocante às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, nada há nos autos que justifique a fixação da pena acima do patamar mínimo legal, motivo pelo qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo, ante a ausência de elementos que possibilitem aferir a real situação econômico-financeira do acusado.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a se aplicar.

Deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é tecnicamente primário (fls. 52/55 e 58/60), não ostenta Maus antecedentes e não há provas de que se dedique às atividades criminosas e esteja envolvido com o crime organizado. A fração de diminuição deve considerar as circunstâncias do caso concreto, o que mostra como justa e suficiente a redução pela metade (1/2), face à natureza e quantidade da droga e apetrechos

apreendidos (45,48 gramas, distribuídas em 54 microtubos plásticos contendo cocaína, além de 02 peneiras com resquícios da droga e mais de 100 microtubos plásticos vazios). Diminuo, portanto, a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo.

Torno definitiva a pena acima imposta, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Conforme entendimento há muito exarado por este magistrado, o crime de tráfico fomenta inúmeros outros crimes e seria o caso de fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, seja por conta de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, seja porque o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja, finalmente, porque o artigo 44, "caput", da Lei nº 11.343/2006, é expresso ao proibir referido benefício, bem como não se consideraria apta para retribuição e prevenção da pena, a mencionada substituição no presente caso. Ressalto que o crime de tráfico de drogas gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, além de verdadeira sensação de impunidade nesta interiorana cidade de Araçatuba-SP.

Contudo, em recente posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP, foi determinada a fixação do regime inicial aberto quando aplicado o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), como se deu no caso em comento.

Nesse sentido, em observância à determinação da Corte Superior, o réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime aberto.

Por conseguinte, o réu tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, por preencher os requisitos do artigo 44, I a III, e parágrafo 2º, do Código Penal. A prestação pecuniária consistirá no pagamento, em dinheiro, do valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente na data do efetivo pagamento, que será revertido em benefício de entidade pública ou privada com destinação social, conforme artigo 45, parágrafo 1º, do Código Penal, observando-se o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 46 e parágrafos do Código Penal) terá seu cumprimento disciplinado pelo Juízo da Execução, conforme as aptidões do réu, e deverá se dar pelo período de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.

Incabível no caso a concessão da suspensão condicional da pena, uma vez que deferida a substituição por pena restritiva de direitos.

DECIDO.

Ante o acima exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Ministério Público e o faço para:

A) CONDENAR o réu DAVI VINICIUS DE FREITAS EVANGELISTA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", cumulado com o parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com regime aberto para o início do cumprimento.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos moldes expostos na fundamentação desta sentença;

B) ABSOLVER a ré TAMIRES MAYARA RODRIGUES DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

C) ABSOLVER os réus DAVI VINICIUS DE FREITAS EVANGELISTA e TAMIRES MAYARA RODRIGUES DA SILVA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Defiro ao sentenciado Davi Vinicius de Freitas Evangelista o direito de recorrer em liberdade, em razão do regime prisional e natureza da pena imposta.

DECLARO o perdimento da quantia apreendida de R\$ 302,00 (fl. 89) em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, bem como a DESTRUIÇÃO dos apetrechos também apreendidos às fls. 16/17 (peneiras e microtubos plásticos vazios), uma vez que inerentes ao crime de tráfico praticado pelo sentenciado, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

Por fim, DETERMINO a restituição do aparelho celular apreendido nos autos (fl. 16) em favor do sentenciado, não restando demonstrada sua relação com o tráfico ilícito de entorpecentes, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

Custas conforme a lei (artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003), observando-se a gratuidade de justiça concedida em favor dos réus (fl. 167).

P. R. e I.

Araçatuba, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA